

1503679-24.2021.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... e legal da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo".

Tal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1503679-24.2021.8.26.0510 -

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503679-24.2021.8.26.0510 - 2021/000768

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAROLAINÉ DE SOUZA BRAZ

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

CAROLAINÉ DE SOUZA BRAZ, qualificada no inquérito, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque, no dia 23 de novembro de 2021, por volta das 19:05 horas, na Avenida 68, com a Rua Jacutinga, Jardim Araucária, nesta Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo 60 (sessenta) microtubos do tipo eppendorf contendo a substância entorpecente denominada cocaína, e ainda guardava e tinha em depósito outros 35 (trinta e cinco) microtubos do tipo eppendorf contendo a mesma substância entorpecente denominada cocaína, totalizando com aqueles outros, peso líquido aproximado de 23,66 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15, laudo de constatação de fls. 17/19 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 42/44, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Regularmente notificada, seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor da

acusada, sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 07 de março de 2022. Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, com posterior interrogatório da acusada.

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação da acusada, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, possibilitando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com fixação de regime prisional inicial aberto, possibilitando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, impondo-se, ainda, o perdimento da importância em dinheiro apreendida em poder da acusada.

Já a ilustre Defensora Pública inicialmente sustentou comprometida a materialidade do delito em função da ilícita busca pessoal que resultou na apreensão do entorpecente, porque em violação ao disposto no artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a determinar a absolvição nos termos do artigo 386, inciso II, do mesmo Estatuto Processual. De outra parte, considerando ser a acusada usuária, relatando que a posse do entorpecente decorreu da perspectiva de obtenção de droga para seu próprio uso, reclamou igualmente a absolvição, diante da excludente da inexigibilidade da conduta diversa, nos termos do disposto no artigo 386, inciso VI, do mesmo Estatuto Processual Penal. No mérito, dizendo insuficiente a prova produzida pelas razões que cuidou em expor, requereu a absolvição, aqui com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, possibilitando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de regime prisional diverso do fechado, com a restituição dos valores apreendidos e facultando-se a interposição de recurso em liberdade.

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se a acusada a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque, trazia consigo e ainda guardava e tinha em depósito, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, o entorpecente indicado na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conquanto incontroversa, a materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. \*\*\*\*\*, com resultado positivo para cocaína.

Sustenta-se que a materialidade do delito estaria comprometida em função de ilícita busca pessoal realizada, em afronta ao disposto no artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal. Entretanto, afirmaram os Policiais Militares que na ocasião estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico de entorpecente, onde se encontrava a acusada, tendo ela tentado empreender fuga, quando da aproximação da guarnição, por isto acabou sendo abordada, seguindo-se a apreensão com ela do entorpecente.

Estar a acusada sozinha em um ponto de venda de entorpecente, tentando encetar fuga quando da aproximação de Policiais Militares, constitui, tendo os olhos postos na realidade, além da consideração do tirocínio policial, fundada suspeita de que estava realizando o comércio ilícito, e isto tanto se mostra tanto mais verdadeiro, que resultou efetivamente na apreensão de dezenas de porções de cocaína com a acusada.

Deste modo, respeitada a objeção deduzida, diante dos elementos concretamente considerados, não se entende ilícita a busca pessoal realizada, a comprometer, por derivação, a materialidade do delito.

Também não socorre a acusada a invocação da excludente da inexigibilidade de conduta diversa, assim porque afirmou que cuidava apenas em transportar entorpecente, porque receberia duas porções de cocaína para o próprio uso. À evidência que não era inexigível conduta diversa, com vistas à obtenção de entorpecente, bastando mencionar que a própria acusada afirmou que possuía na ocasião a quantia de cem reais.

Ouvida em Juízo, a acusada afirmou que na ocasião dos fatos, nas proximidades do

local onde foi abordada, foi instada por um terceiro a transportar o entorpecente, que logo em seguida foi apreendido em seu poder. Negou que estivesse naquele local realizando o comércio ilícito, como também que estivesse guardando em um cano de água pluvial o restante do entorpecente que foi, a final, localizado e também exibido pelos Policiais Militares à d. Autoridade Policial. Todavia, a versão deduzida pela acusada foi contrariada pela prova produzida. De fato, os Policiais Militares ouvidos em juízo, reiterando o que exposto contemporaneamente aos fatos, afirmaram que na ocasião estavam em patrulhamento pelo local, já conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando por lá avistaram a acusada, que se encontrava sozinha, tendo ela tentado empreender fuga, mas acabou abordada, admitindo posteriormente que portava o entorpecente que espontaneamente exibiu, tratando-se de sessenta porções de cocaína, que estava sob suas vestes, além da quantia de vinte e dois reais em dinheiro. No curso da abordagem, um popular, morador na localidade, informou que a acusada ainda guardava entorpecente nas proximidades, no interior de um cano de água pluvial, onde efetivamente foram localizadas outras trinta e cinco porções da mesma substância, embalada de forma idêntica.

Como se tem afirmado, à míngua de elemento que demonstre efetivamente algum abuso, não há de se desmerecer o depoimento dos policiais militares envolvidos nas diligências. A propósito: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54). Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu).

Além da idoneidade de que goza o depoimento dos policiais militares, cumpre ressaltar que parte do entorpecente foi apreendida no interior de um cano de água pluvial, cuja localização só foi possível em função da informação recebida, como dito por eles, de um terceiro, que por sua vez assim se manifestou porque tinha conhecimento da movimentação exercida pela acusada naquele local.

Deste modo, as circunstâncias indicadas não apenas revelam a posse do entorpecente, mas também a sua destinação mercantil, reforçada pela quantidade e armazenamento de parte da droga, escondida nas proximidades, em um cano de água pluvial, como se tem comumente verificado no exercício do comércio ilícito.

Acresça-se que a acusada, como exposto, estava em gozo de liberdade provisória, atribuindo-se-lhe a prática do mesmo delito, a permitir, portanto, em associação aos demais elementos probatórios, seguro juízo de convicção sobre a imputação inicial.

Isto considerando, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, diante das circunstâncias pessoais e judiciais favoráveis, não sendo, ademais, expressiva a quantidade de entorpecente apreendida, possível seja fixada a

pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, deve pena-base cominada ser reduzida em função do que disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Este dispositivo legal cuida da possibilidade de operar-se a redução da pena, quando se tratar de réu primário, de bons antecedentes, não integrante de organização criminosa e que não esteja dedicado ao comércio ilícito.

A acusada é primária e, embora ostente registro criminal semelhante, ainda não definitivo, a concorrer em seu favor a presunção de inocência, tal se deu de forma distanciada no tempo (2019), sem outros registros criminais posteriores, a possibilitar a conclusão de que não estava dedicada ao comércio ilícito, premida ainda por circunstâncias decorrentes da drogadição, a autorizar a causa especial de diminuição de pena, em seu grau máximo, porquanto não expressiva a quantidade apreendida de entorpecente, devendo a pena-base ser reduzida em 2/3 (dois terços), totalizando 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica da acusada.

Diante da operada redução da pena inicialmente cominada, caracterizando a figura do tráfico privilegiado, devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento que se consagrou no Colendo Supremo Tribunal Federal e Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Sobre isto, revendo entendimento consolidado anteriormente, com consequente cancelamento da Súmula nº 512, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que o tráfico de entorpecente, em sua forma privilegiada, não tem natureza hedionda. Segundo o decidido, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no artigo 33 caput e §1º, da Lei 11.343/06 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa".

Além disto, destacou-se que, apesar da vedação constitucional e legal da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo".

Tal entendimento decorreu do posicionamento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em acórdão relatado pela Ministra Carmem Lúcia, observando-se que a decisão do legislador fora no sentido de que o agente deveria receber tratamento distinto daqueles sobre os quais recairia o alto juízo de censura e de punição pelo tráfico de drogas e de que as circunstâncias legais do privilégio demonstrariam o menor juízo de reprovação e, em consequência de punição (HC 118.533/MS, 23/06/2016).

Acrescentou-se que, nem toda transação ilícita com drogas deve necessariamente submeter-se ao regime dos crimes hediondos, como a conduta de quem oferece droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem (art. 33, §3º, Lei 11.343/06), bem como a de quem, de forma episódica, pratica o denominado tráfico privilegiado (art. 33 §4º, Lei 11.343/06).

Nesta linha de raciocínio, consignou-se que o artigo 44 da Lei de Tóxicos, ao estabelecer que os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 a 37 da Lei 11.343/06 "são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos", conferiu ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º), tratamento especial ao que o legislador atribuiu ao caput e ao §1º do artigo 33, a reforçar a tese de que não se trata de delito hediondo.

Ainda segundo o que decidido, o conceito de hediondez é de todo incompatível ao de privilégio, conforme há muito vem decidindo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no que diz com o homicídio qualificado-privilegiado, não se lhe aplicando o disposto na Lei 8072/90, afastando, portanto, a natureza hedionda. Concluiu-se que

o julgamento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ainda que por seu Órgão Pleno, não tem efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, nos termos do artigo 927, §4º, do Código de Processo Civil, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito daquele Egrégio Tribunal Superior, entendeu-se ser necessária a revisão da questão, com a determinação da revisão do entendimento anterior, estabelecendo-se a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada não é crime equiparado a hediondo.

Assim, cumpre seja a pena privativa substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena cominada, a ser dirimida em execução, como também por uma pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 33, "caput", c.c. § 4º da Lei nº 11.343/06, CONDENO a acusada CAROLAINÉ DE SOUZA BRAZ à pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, a ser dirimida em execução, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigido desde a época do fato, como também de pena pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo.

Em caso de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, esta deverá ser cumprida em regime prisional inicial aberto.

Diante da pena cominada, faculto a interposição de recurso em liberdade, com expedição de alvará de soltura clausulado em favor da acusada.

Oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA